

笔者认为,《中华人民共和国刑法》第一百四十四条规定的“掺入”的行为不仅限于指向产品本身,还可能针对产品的原料、半成品等,甚至还可以指向食品添加剂,即在食品添加剂内掺入有毒、有害物质。而所谓“有毒、有害的非食品原料”,是指对人体具有生理毒性,食用后会引起不良反应,损害机体健康的不能食用的原料。

淋巴结是猪屠宰后检疫的一个重要指标,相关资料表明,它是机体外周的免疫器官和防御结构,具有吞噬异物和各种微生物的功能,并产生免疫应答。当机体某组织或者器官受到病原微生物侵害时,很快被局部淋巴结阻截,并发生相应的变化,使淋巴结体积增大或缩小,色泽呈现出红、黑、青等。故,淋巴结含有大量的病原微生物,如一些细菌、病毒等,甚至会有3,4-苯并芘等致癌物质,且本身没有营养。因此,上述猪肉废弃物应当属于有毒、有害的非食品原料。刘某等人利用含有淋巴结的猪边角肉、猪脚油、猪血槽修割物、碎皮等猪肉废弃物生产、加工食用油,应当认定为掺入有毒、有害的非食品原料。

实践中,健康猪经屠宰后,取其新鲜、洁净和完好的脂肪组织炼制而成的油脂。所用的脂肪组织不包含骨、碎皮、头皮、耳朵、尾巴、脏器、甲状腺、肾上腺、淋巴结、气管、粗血管、沉渣、压榨料及其他类似物,应尽可能不含肌肉组织和血管。刘某等人利用含有毒、有害非食品原料的猪肉加工废弃物生产、加工食用油,对涉案食用油无须由鉴定机构出具鉴定意见,即便检测报告有关理化指标合格,也可以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。

针对“地沟油”案件,直到当前也没有形成一种公认的、行之有效的鉴定方法。因此,惩治危害食品安全的犯罪,不能完全依赖于鉴定机构的鉴定,对“地沟油”的鉴定意见不应是司法机关认定“有毒、有害食品”的唯一依据。实践中,应当结合技术标准和法学标准对“有毒、有害食品”进行判定。对于有确实、充分的证据证实行为人在食品中掺入国家行业主管机关明令禁止使用的非食用物质的,对涉案食品不需由鉴定机构出具鉴定意见。

综上,含有淋巴结的猪边角肉、猪脚油、猪血槽修割物、碎皮等猪肉废弃物等非食品原料属于《中华人民共和国标准化法》等国家标准明确排除使用的

食用猪油炼制原料，行为人以上述原料炼制食用猪油，属于在生产过程中掺入有毒、有害原料，其生产、销售行为构成生产、销售有毒、有害食品罪。

编写人：重庆市第三中级人民法院
崔鲁

有毒、有害食品作为赠品与其他食品捆绑销售的刑法评价①

—— 王某等销售有毒、有害食品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济南市中级人民法院(2022)鲁01刑终553号刑事裁定书

2. 案由：销售有毒、有害食品罪

【基本案情】

自2018年7月起，被告人王某代理“A”系列产品予以销售，其中包括果冻、蛋卷、植物肽果蔬压片糖果(分“早糖”和“晚糖”)等。王某发展了被告人刘某某、杨某等人为代理商。王某、刘某某、杨某等人明知“早糖”含有有毒、有害物质，仍采用销售两盒果冻赠送一盒“早糖”的模式进行销售，销售及消费者购买除早糖外其他系列减肥产品均依托于“早糖”的功效。经检验，植物肽果蔬压片糖果(早糖)含有西药“西布曲明”成分，其系《保健食品中可能非法添加的物质名单》中

的物质。被告人王某销售果冻搭配“早糖”金额122660 元，非法获利58539 元；被告人刘某某销售果冻搭配“早糖”金额116921元，非法获利7220元；杨某销售果冻搭配“早糖”金额110361元，非法获利8240元。

① 入库案例，参见人民法院案例库2023-02-1-072-011。

【案件焦点】

1. 商品交易中赠与赠品是否属于销售商品；2. 销售者对赠品含有有毒、有害物质明知的认定；3. 在捆绑销售模式中有毒、有害食品销售数额如何认定。

【法院裁判要旨】

山东省济南市历城区人民法院经审理认为：被告人王某、刘某某、杨某违反食品卫生管理法规，销售明知掺有毒、有害非食品原料的食品，其行为均已构成销售有毒、有害食品罪。王某、刘某某、杨某销售有毒、有害食品的销售金额分别为122660元、116921元、110361元，金额在10万元以上不满20万元的，但销售持续时间在六个月以上，故应认定为销售有毒、有害食品具有其他严重情节。王某、刘某某退缴涉案款项，酌情从轻处罚。据此，一审以销售有毒、有害食品罪分别判处王某六年六个月，并处罚金50万元；刘某某有期徒刑五年十个月，并处罚金40万元；杨某有期徒刑五年五个月，并处罚金35万元；判处没收三被告的作案工具及违法所得；判处王某向人民检察院支付侵害消费公共利益的损害赔偿款1226600元，被告人刘某某对上述赔偿款中的1169210元与王某承担连带责任，被告人杨某对上述赔偿款中的1103610元与王某、刘某某承担连带责任。

宣判后，三被告人均提出上诉。

山东省济南市中级人民法院审理认为：原审认定的事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案为一起典型的捆绑销售“问题赠品”刑事案件，处理重点在于赠与视为销售的认定、销售者对赠品中含有有毒、有害物质明知的认定、及捆绑销售模式中销售数额的认定。

在赠与赠品是否视为销售问题上，因刑法规范中欠缺直接规定，可参照民法等部门法进行评价。根据《中华人民共和国民法典》第六百六十二条的规定，附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出

卖人相同的责任。赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担赔偿责任。《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》也明确，商家应当对赠品质量安全承担责任；食品、药品生产者、销售者提供给消费者的食品或者药品的赠品发生质量安全问题，造成消费者损害的，消费者主张权利，生产者、销售者以消费者未对赠品支付对价为由进行免责抗辩的，人民法院不予支持。从上述法律法规的规定来看，商品交易中赠与赠品行为等同于销售。本案中，三被告人均采用销售两盒果冻赠送一盒“早糖”的固定模式进行捆绑销售，而赠品“早糖”含有“西布曲明”成分，故将含有“西布曲明”成分的赠品“赠与”等同于销售有毒、有害食品行为。

销售者对赠品中含有有毒、有害物质明知的认定问题主要应审查对明知程度的把握、及推定明知的适用。司法实践中，绝大多数销售者对食品安全无专业知识背景，苛求销售者具体了解、确切知道其所销售食品中含有哪些成分和物质不切实际，因此对销售者的明知程度应以可能的明知来认定，即只要明知可能含有有毒、有害物质即可，并不需要对具体成分予以明确。而这种明知的认定是推定所得，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定了生产、销售有毒、有害食品罪中“明知”的推定情形，将主观构成要素内涵问题转化为形式推定要素的程序性证明问题，此外，推定“明知”还存在以下常见情形应予关注：一是食品包装是否规范、食品安全信息是否完备；二是销售者是否知晓该食品具有副作用等；三是具体销售行为是否异常。本案中，“早糖”系外包装无生产日期、生产厂家和质量检验合格证明等标识的食品；同时，三被告人在销售过程中均强调的禁忌及服用后果明显超出正常食品应注意的事项范畴；还存在多被害人陈述“早糖”副作用明显询问三名被告人等情形。上述事实足以认定三被告人对所销售减肥药系有毒、有害食品的事实是明知的。

对捆绑销售模式中销售数额的认定，应将正常商品与赠品捆绑销售的数额全部认定为犯罪数额。因正常商品是为配合“赠品”才生产、购进，销售者整体的捆绑销售行为本身就是为销售含有有毒、有害物质的赠品而设定，所谓“赠

品”只是一种包装和假象，与正常商品密不可分，“赠品”有名无实，甚至反客为主，是真正的销售目标和盈利来源；同时，赠品也是销售者用来逃避法律规制的手段，销售者利用“赠品”名义逃避检查、打击，掩饰销售有毒、有害食品之实，虚化有毒、有害食品的销售数额。故此，这种情形下不宜将正常商品与赠品销售数额作出区分，而应以捆绑销售的整体数额认定犯罪数额。本案中，三被告人在明知“早糖”中含有有毒、有害物质，减肥功效依托于“早糖”的情况下，以销售减肥产品的名义，采用销售果冻赠“早糖”的模式对外捆绑销售，将“早糖”作为无定价赠品裹附于合法产品的外衣下，掩盖其销售有毒、有害食品的实质，虚化销售有毒、有害食品的数额，应以果冻和“早糖”捆绑销售的数额认定为三被告人销售有毒、有害食品的犯罪数额，并据此对三被告人科处相应刑罚。

编写人：山东省济南市中级人民法院 孙勇
李广大

（二）走私罪

24

走私淫秽书籍和其他书籍入境销售，分别构成 走私淫秽物品罪和走私国家禁止进出口的货物罪

——何某某走私淫秽物品、走私国家禁止进出口的货物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

南昌铁路运输中级法院（2023）赣71刑初2号刑事判决书

2. 案由：走私淫秽物品罪、走私国家禁止进出口的货物罪

【基本案情】

2013年至2021年，被告人何某某以牟利为目的，在不具备出版物进口经营许可的情形下，陆续从境外出版商、经销商处购买淫秽漫画、淫秽小说和其他书籍。何某某通过委托某1物流公司、某2物流公司等物流公司，将大量淫秽书籍和其他书籍以伪报、夹藏等方式走私入境，运至何某某租用的仓库；或由出版商、经销商以包物流等方式，将何某某购买的书籍走私运输入境，运至何某某租用的仓库。被告人何某某利用其父亲王某江注册设立的某书店，先后在网络平台设立多个网店，并雇用成某、刘某、陆某、胡某、杨某(均另案处理)等人帮其收货、整理入库、销售、发货等。

海关缉私局于2021年11月12日立案后，先后对何某某租用的4个仓库内的书籍进行搜查扣押；2021年12月3日在物流点扣押何某某走私入境书籍287纸箱。上述扣押书籍共计38万余册。2021年11月，何某某委托某2物流公司承运的17713册书籍(重8.11余吨)，被福州海关查获。经鉴定，扣押涉案书籍有1593种为淫秽书籍。经匹配销售记录，何某某通过网店已销售淫秽书籍48030册，其他书籍244110册(重94余吨)；现场查扣淫秽书籍共计59977册，其他书籍计重158余吨。综上，何某某走私淫秽书籍共计108007册，走私其他书籍共计重252余吨。

【案件焦点】

行为人将淫秽书籍和其他书籍一并走私入境销售，对其中的非淫秽书籍如何定性。

【法院裁判要旨】

南昌铁路运输中级法院经审理认为：被告人何某某以牟利为目的，逃避海关监管，明知所购书籍系淫秽书籍或国家限制进出口的书籍，仍向境外出版商、经销商订购，并伙同他人将上述书籍走私入境，在网店销售牟利；同时长期参与境外出版商、经销商走私书籍的收、发货。走私淫秽书籍10.8万余册，走私限制进出口的书籍252余吨，均属情节严重，其行为分别构成走私淫秽物品罪、

走私国家禁止进出口的货物罪。应依法处罚且数罪并罚。在走私淫秽物品罪、走私国家禁止进出口的货物罪的共同犯罪中，何某某均起主要作用，系主犯；何某某归案后揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，依法可以从轻处罚；何某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；何某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。何某某主动退缴违法所得，可对其酌情从轻处罚。据此，判决如下：

一、被告人何某某犯走私淫秽物品罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币400万元；犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处没收财产人民币400万元、罚金人民币100万元；

二、扣押在案的物品，被告人何某某退缴的违法所得人民币30万元，由南昌海关缉私局依法处理。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

此类案件中，在走私的书籍中往往混杂了淫秽书籍和大量其他书籍。上述书籍危害人们身心健康，对未成年人造成负面影响，污染了社会文化安全和文化市场秩序。法院审理此类案件，对淫秽书籍和非淫秽书籍作出全面刑法评价，进行罪数评判。

《出版管理条例》对于“进口出版物”实行“特定经营主体”和“进口出版物备案”管理。出版物进口业务职能由依照该条例设立的出版物进口经营单位经营，其他单位和个人不得从事出版物进口业务。该条例第二十五条规定，任何出版物不得含有下列内容：(1)反对宪法确定的基本原则的；(2)危害国家统一、主权和领土完整的；(3)泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；(4)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；(5)宣扬邪教、迷信的；(6)扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；(7)宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的；(8)侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；(9)危害社会公德或者民族优秀传统文化的；(10)有法

律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。第二十六条规定，以未成年人为对象的出版物不得含有诱发未成年人模仿违反社会公德的行为和违法犯罪的行为的内容，不得含有恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的内容。《中华人民共和国海关进出境印刷品及音像制品监管办法》第十二条规定，除国家另有规定外，进口报纸、期刊、图书类印刷品，经营单位应当凭国家新闻出版主管部门的进口批准文件、目录清单、有关报关单证以及其他需要提供的文件向海关办理进口手续。根据上述规定，书籍进口需要备案并需要审核，有资质的出版机构才可以正常进口，属于需要许可的国家限制进出口的货物、物品。淫秽书籍则属于《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第一款具体列举的国家禁止进出口的淫秽物品。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第二十一条规定，未经许可进出口国家限制进出口的货物、物品，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条、第一百五十二条的规定，以走私国家禁止进出口的货物、物品罪等名定罪处罚。无资质的行为人大量从境外走私书籍入境销售，其中淫秽书籍构成走私淫秽物品罪；非淫秽书籍可能构成走私国家禁止进出口的货物罪，也可能构成走私普通货物罪。本案，何某某在8年间，走私淫秽书籍108007册，走私其他书籍252余吨，其他书籍偷逃应缴税额已无法计核的情况下，分别以走私淫秽物品罪、走私禁止进出口货物罪定罪并处。

综上，对于跨境走私书籍犯罪的定性，应当根据淫秽书籍和非淫秽书籍所侵害的不同法益，准确进行罪数评判。贯彻罪责刑相适应的刑法基本原则，以数罪并罚，实现刑法对犯罪行为的全面评价。

编写人：南昌铁路运输中级法

院 周莉 江西省高级人

民法院 贾飞扬

单位及单位成员的追诉时效既应当保持同步又相互独立

—— 陈某某等走私普通货物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02刑初27号刑事判决书

2. 案由：走私普通货物罪

【基本案情】

某公司成立于2013年11月，被告人陈某某系该公司股东，负责公司全部经营。2014年2月至2015年5月，在陈某某的决策下，某公司将其采购的本应以一般贸易方式进口的境外商品，委托林某以“对台小额商品交易市场”方式免税申报进入某市场。林某接受委托后办理相关境外商品的通关进口手续，并通过虚构个人在某市场购买消费的方式，“化整为零”将货物运出某市场交付给某公司用于在境内销售牟利。经查，某公司以上述方式先后走私境外商品共8票，经计核，偷逃应缴税款336620.28元。

被告单位某1公司成立于2016年7月，被告人陈某某系该公司法定代表人、股东，负责公司全部经营。2019年1月至2022年4月，在陈某某的决策下，某1公司以低报价格的方式

从境外进口食品共计93票。经计核，偷逃应缴税款1147557.39元。

2022年4月15日，被告人陈某某自动到海沧海关缉私分局投案并如实供述了某公司、某1公司走私的事实。

【案件焦点】

1. 某公司的犯罪行为是否适用追诉时效制度；2. 某公司已过追诉期限，单位成员的罪责是否随之绝对灭失。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：某公司伪报贸易性质走私普通货物入境，偷逃应缴税额336620.28元；被告单位某1公司违反海关法规，逃避海关监管，以低报价格的方式走私普通货物入境，偷逃应缴税额1147557.39元，情节严重；被告人陈某某作为上述单位走私直接负责的主管人员，在单位犯罪中均起领导、决策作用，共计偷逃应缴税额1484177.67元，数额巨大。某1公司、陈某某的行为均已构成走私普通货物罪。本案某公司走私部分系共同犯罪。陈某某作为某1公司直接负责的主管人员，自动投案并如实供述所犯罪行为且认罪认罚，某1公司、陈某某均具有自首情节，依法均可对某1公司、陈某某从轻或者减轻处罚并从宽处理。陈某某代某1公司预缴罚金，可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节等，决定对某1公司从轻处罚，对陈某某减轻处罚并适用缓刑。据此，判决如下：

一、被告单位某1公司犯走私普通货物罪，判处罚金人民币115万元；

二、被告人陈某某犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；

三、扣押于侦查机关的作案工具被告人陈某某的手机一部，予以没收；

四、被告人陈某某代被告单位某1公司预缴的罚金人民币115万元用于执行判决第一项。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

单位犯罪是否适用刑法追诉时效的规定，法律没有明确规定。本案的争议焦点是第一起某公司实施的走私犯罪是否适用刑法追诉时效的规定，如果某公司犯罪行为已经过追诉时效不再追究刑责，其直接主管人员即被告人陈某某是否亦随之绝对豁免不再承担相应罪责。

